

1503781-65.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Leonardo de Mello Gonçalves

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/07/2022

... estavam. Contou que existe um ponto de tráfico de drogas próximo à sua casa. Negou ter comercializado qualquer droga como afirmado pelos policiais. Afirmou que a única ligação que tem com o tráfico é a compra de maconha, em razão da sua condição de usuário. Contou que o seu cunhado também é usuário de maconha. Disse que em nenhum momento ocorreu a perseguição narrada pelos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

2ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-190

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503781-65.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503781-65.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2312201/2021 - DISE- DEL.SEC.SANTOS, 2312201 - DISE- DEL.SEC.SANTOS, 133/21/218 - DISE- DEL.SEC.SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAPHAEL DO NASCIMENTO LEAL

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo de Mello Gonçalves

Vistos.

RAPHAEL DO NASCIMENTO LEAL, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Conforme narra a denúncia, no dia 16 de novembro de 2021, por volta das 17h, na Rua Liberdade, 764, Liberdade, nesta cidade e comarca, o acusado guardava 238 porções de cocaína (cerca de 136 gramas), e 70 porções maconha (cerca de 218 gramas), para a entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo consta, policiais civis efetuavam diligência investigativa pelo local dos fatos, em razão de terem apurado, por meio de investigação de campo, que um indivíduo estaria traficando naquele local, utilizando a residência para guardar as drogas.

Com o uso de viatura descaracterizada, os policiais civis realizaram vigilância no local apontado, ocasião em que avistaram o acusado em atitude típica de tráfico,

quando era abordado por um transeunte, se dirigia à sua residência, retornava logo em seguida e entregava algo para tal pessoa.

Os investigadores decidiram realizar a abordagem do acusado, ocasião em que ele saiu correndo e ingressou em sua residência, sendo perseguido e detido pelos policiais.

Indagado sobre a existência de entorpecente no imóvel, o acusado admitiu aos investigadores que guardava drogas em seu quarto.

No referido cômodo, os investigadores localizaram as 238 porções de cocaína e as 70 porções de maconha, além de um aparelho celular.

A quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas e as demais circunstâncias da apreensão evidenciam que o entorpecente se destinava ao comércio ilícito.

Auto de prisão em flagrante (fls. 01/02). Boletim de ocorrência (fls. 03/06). Auto de exibição e apreensão (fls. 07).

O réu foi notificado (fls. 152) e ofertou defesa prévia (fls. 73/77).

Fotos da porta da residência do acusado (fls. 81/86).

A denúncia foi recebida em 14/01/2022 (fls. 101/104).

Laudo pericial dos entorpecentes apreendidos (fls. 105/109).

O réu foi citado (fls. 156). Laudo pericial do celular do acusado (fls. 230/237).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, três testemunhas de defesa, bem como realizado o interrogatório do réu.

Em memoriais, o Ministério Público, pugnou pela procedência da ação penal.

Sustentou que a materialidade do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/06, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 07, pelo laudo pericial de fls. 107/109, bem como pela prova oral produzida em juízo. Alegou que a autoria é certa e recai inegavelmente sobre o réu, em especial pela prova oral produzida.

Aduziu que as declarações prestadas pelas testemunhas de defesa, negando o encontro da droga do imóvel e buscando macular a diligência policial realizada no imóvel não merecem prosperar. Sustentou que a testemunha de defesa Cristiano narrou ter visto a prisão do réu, quando se deslocava para ir até a pizzaria, por volta das 18 horas, horário que não coincide com o início da diligência policial. Sustentou que os relatos apresentados pelas testemunhas de defesa não desnaturam o sólido conjunto probatório coligido aos autos, em especial pelos depoimentos firmes e coesos dos policiais civis. Aduziu que como o tráfico de drogas é um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável para sua comprovação, desde que apontada a sua ocorrência por outros meios de prova. No que tange à dosimetria da pena, na primeira fase, pugnou pela fixação da pena-base acima do mínimo em razão da expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, nos termos do artigo 46 da Lei nº 11.343/2006. Na segunda fase, requereu o reconhecimento da reincidência específica do acusado. Na terceira e última fase, postulou pela não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, devido à reincidência específica do acusado. Por fim, pugnou pela fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, uma vez que o crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo.

A D. Defesa, por sua vez, também em memoriais, pugnou pela improcedência da ação penal. Requereu o reconhecimento da ilegalidade da busca e apreensão realizada na casa do acusado, com a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. Alegou que não havia justo motivo para o ingresso forçado na residência do acusado, pois como fizeram campanhas anteriores à prisão do acusado, não havia motivos para deixar de postular a expedição de um mandado de busca e apreensão para justificar o ingresso no imóvel. Sustentou que conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a denúncia anônima e a fuga não são motivos suficientes para a violação do domicílio por parte dos policiais na hipótese de flagrante em crimes permanentes, quando não acompanhados de fundadas razões da sua prática ou de mandado de busca e apreensão. Aduziu que as provas amealhadas aos autos são frágeis no que tange à autoria delitiva, não havendo elementos que expressem ou indiquem com segurança que a droga apreendida estava sob a posse do acusado. Desta forma, postulou pela aplicação do princípio do in dubio pro reo, com

a consequente absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, incisos IV ou VII, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é improcedente.

A materialidade delitativa não pode ser atribuída ao acusado, uma vez que o flagrante realizado no dia 16/11/2021 se mostrou ilegal, pois na ocasião, os policiais entraram no imóvel sem mandado de busca e apreensão, e conforme se percebe dos autos, o mesmo era possível, pois foram realizadas campanhas em dias anteriores, demonstrando que havia tempo hábil para pleitear o competente mandado de busca e apreensão.

A testemunha de acusação, FÁBIO LUIZ AGUINO DE CASTRO, policial civil, afirmou que o local dos fatos é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Relatou que em dois dias anteriores aos fatos, observou o acusado saindo de sua residência, encontrando terceiros na ponte do canal 06, entregando algo a eles, e retornando até a sua casa, repetindo essa dinâmica diversas vezes. Disse que fotografou toda essa movimentação do acusado. No dia dos fatos, foi até a residência do acusado e, realizando breve campanha com uma viatura descaracterizada, observou o acusado saindo de sua casa, atravessando a ponte do canal 6, e entregando algo a terceiros. Percebendo que o acusado pretendia repetir tal movimentação, tentou abordá-lo, oportunidade em que o acusado correu até a sua residência e houve uma perseguição. Relatou que o policial Heitor logrou êxito em alcançar o acusado na sala. Observando que outras pessoas também estavam na casa, adentrou no fundo da casa para realizar a contenção. No interior da residência, estavam o acusado, sua mãe, sua irmã, seu cunhado e uma manicure. Durante a sua abordagem, o acusado confessou informalmente a prática do delito, afirmando que guardava drogas em seu quarto. Contou que os entorpecentes foram encontrados em um rack em seu quarto, totalizando mais de duzentos pinos de cocaína, e cerca de setenta porções de maconha. Relatou que a irmã e o cunhado do acusado também foram conduzidos à delegacia, pois o seu companheiro também é envolvido com o tráfico de drogas. Chegando no local, o acusado permaneceu em silêncio. Contou que conhecia o acusado de vista, através de rondas realizadas pela redondeza. Afirmou que não solicitou uma ordem judicial de busca e apreensão em razão do tempo que demoraria para elaborar um relatório completo, pois tinha certeza de que as drogas estavam no local, tomando o risco de entrar na residência do acusado sem mandado. A busca foi realizada por toda a residência, sendo que a mãe e a irmã o acompanharam. Não soube indicar o motivo pelo qual transcorreu, cerca de quatro ou cinco horas, desde o início da busca até a lavratura do boletim de ocorrência. Relatou que a abordagem do acusado ocorreu a cerca de dois metros de sua residência. Contou que o acusado trabalha para um indivíduo conhecido como "MK", tendo acesso a essa informação através da realização da prisão de outros indivíduos.

A testemunha de acusação, HEITOR DIAS VIEIRA, policial civil, disse que o local dos fatos é conhecido como ponto de tráfico de drogas, passando rotineiramente por lá. Dois dias antes dos fatos, através da realização de breve campanha, observou o acusado indo até terceiros, realizando venda, e voltando para casa, em três oportunidades; inclusive registrando essas transações em fotos e vídeos. Não efetuou a prisão em flagrante do acusado nestas ocasiões, pois queria confirmar onde estavam as drogas. Na data dos fatos, solicitou o apoio de outra viatura, pois não sabia quantas pessoas estavam na casa. Relatou que como o acusado sempre retornava para sua residência, sabia que as drogas estavam armazenadas neste local. No momento em que foi realizar a abordagem do acusado na rua, ele fugiu para a sua casa, sendo abordado em sua sala, enquanto os seus parceiros foram para o fundo das residência. O acusado indicou que as drogas estavam em seu quarto, local em que encontrou mais de duzentas porções de cocaína, e cerca de 70 porções de maconha. Relatou que a busca no quarto do acusado foi acompanhada pelo chefe da polícia, bem como pela sua mãe. Afirmou que nos outros cômodos também sempre havia alguém para acompanhar a busca. Não soube determinar quanto tempo foi necessário para a realização da diligência. Afirmou que o acusado seria o suposto gerente de um traficante conhecido como "MK".

A testemunha de defesa, CRISTIANO TEIXEIRA BARBOSA JÚNIOR, disse que estava tirando sua moto da garagem para ir trabalhar, por volta das 17h50min, quando avistou os policiais saindo de um veículo Siena vermelho. Quando o mencionado veículo estacionou, o policial com barba grande lhe olhou com uma arma na mão, e foi em direção à casa do acusado. Afirmou que o portão da frente da casa do acusado estava fechado, quando passou na frente do imóvel. Contou que a sua casa fica por volta de sete a dez casas da pizzaria, no sentido do canal. Afirmou que os motoboys ficam do lado de fora da pizzaria esperando entrega. Relatou que o acusado não foi perseguido pelos policiais, não havendo ninguém na rua no momento em que ele foi abordado. Por volta das 21 horas, viu uma viatura do DEIC, da qual o acusado saiu algemado com as mãos para trás. Dentro da viatura estava o acusado, sua mãe e sua irmã. Ao tempo da prisão do réu estava trabalhando na pizzaria Nostra Santista localizada na Rua Joaquim Montenegro. Afirmou que trabalhava com o acusado na Nostra Santista, como motoboy, das 18 às 00h. Afirmou que sua casa fica entre a casa do acusado e a pizzaria, passando na frente do local de moto. Acredita que o acusado já foi preso em outras oportunidades.

A testemunha de defesa, VANEZA ALVES DE JESUS, disse que no dia dos fatos, estava na casa do acusado fazendo as unhas da sua mãe, quando ele foi preso. Foi chamada pela sua mãe para realizar o seu serviço de manicure, chegando por volta das 15 horas. Relatou que estava na cozinha, com a mãe e a irmã do acusado, no cômodo mais afastado da residência. A irmã do acusado, após ter escutado um barulho, foi ver o que havia acontecido e, ao retornar à cozinha, começou a falar “meu Deus, meu Deus, o que é isso”. Neste momento, viu um homem com uma arma dizendo que era policial, o qual apontava a arma para os presentes na casa, levando-as para sala. Neste cômodo, o acusado estava sentado e já havia sido algemado com as mãos para trás. Relatou que ao todo estavam cerca de quatro ou cinco policiais na casa, os quais andavam pela casa inteira revirando tudo. Afirmou que ninguém foi convidado para acompanhar a busca, saindo do local por volta das 23h, perdendo vários horários com clientes que já havia marcado. Apesar de os policiais terem afirmado que encontraram drogas, não viu os policiais saindo com qualquer entorpecente ou sacola como afirmaram. Relatou que a entrada da casa é pela sala, e depois teriam dois quartos, e a cozinha, um pouco mais afastada, somente sendo possível sair pela entrada. Desta forma, afirmou que o acusado não saiu do imóvel, pois de tempos em tempos, ia até a cozinha para conversar, bem como que caso ele saísse, o portão com uma tranca e um ferrolho bem grande faria barulho. Contou que o réu trabalha como motoboy, em uma pizzaria localizada próxima de sua casa. Disse que mora na Rua Francisco de Souza Dantas, Marapé, em Santos. Conhece a mãe do réu há muitos anos, pois o irmão de Isley era seu vizinho. Relatou que os policiais chegaram por volta das 16h45min. Na residência estava com o acusado, sua mãe, sua irmã e seu cunhado. O acusado e seu cunhado foram algemados e levados. Sabia que Gabriel estava na casa, pois ele passou pela cozinha e pelo corredor. Os policiais nada perguntavam ou falavam, somente mandando os presentes ficarem quietos. Relatou que os policiais apreenderam o celular de todos os presentes, devolvendo-os ao final da diligência.

A testemunha de defesa ISLEY SOUZA DO NASCIMENTO, genitora do réu, afirmou que na data dos fatos, estava na cozinha fazendo sua unha quando de repente escutou um barulho, razão pela qual sua filha foi para o corredor. Nesta oportunidade ela se deparou com diversas pessoas entrando em sua casa, com armas na mão gritando para que todos se calassem, motivo pelo qual pensou que fosse um assalto. Relatou que os policiais afirmaram que caso não se calasse, seria algemada junto com o acusado. Ato contínuo, os policiais levaram todos os presentes até a sala, recolhendo os seus celulares. Chegando na sala, se deparou com o acusado algemado, sentado no sofá. Contou que os policiais reviraram a sua casa completamente, sem qualquer acompanhamento. Afirmou que Gabriel, companheiro de sua filha, chegou um pouco antes dos policiais, passando pela cozinha e dando boa tarde para os presentes, antes de se dirigir até o seu quarto localizado nos fundos do imóvel. Apesar de os policiais terem afirmado que encontraram drogas no quarto do acusado, não viu os policiais apreenderem qualquer entorpecente. Afirmou que cerca de cinco policiais foram até a sua residência para realizar a prisão do acusado. Relatou que os policiais apresentaram comportamento agressivo durante toda a diligência. Afirmou

que o acusado não saiu de casa em nenhuma parte da tarde, bem como que sua prisão ocorreu no imóvel. Contou que apesar de os policiais terem afirmado que o acusado seria conduzido à delegacia, não presenciou eles encontrando qualquer tipo de entorpecente. Afirmou que o acusado trabalha como motoboy na pizzaria Nostra Santista, das 18h até as 00h. Disse que o acusado foi processado em outra oportunidade por prática de tráfico de drogas. Não sabe o motivo pelo qual os policiais inventariam que o acusado possuía drogas no seu quarto.

A testemunha de defesa, BEATRIZ VITÓRIA DO NASCIMENTO LEAL, irmã do acusado, afirmou que no dia dos fatos, estava na cozinha com sua mãe e Vaneza, quando ouviu um barulho de arrombamento muito alto vindo do portão, também ouvindo sons de passos se aproximando. Em razão disso, foi até o corredor para tentar entender o que estava acontecendo. Nesta oportunidade, viu dois policiais armados entrando na residência. Inicialmente, pensou se tratar de um assalto, uma vez que os policiais não estavam fardados. Devido à entrada abrupta dos policiais, passou a indagá-los sobre o que estava acontecendo, os quais responderam ordenando todos a se calarem. Em sequência, perguntou aos policiais se eles possuíam mandado para autorizar a entrada no imóvel. Os policiais, afirmaram que não possuíam ordem judicial, novamente mandando calar a boca, alertando que se continuasse falando, seria algemada junto com o acusado. Ato contínuo, conduziram os presentes até a sala, apreendendo os seus celulares. Chegando neste cômodo, encontrou o acusado sentado no sofá, já algemado. Contou que permaneceu sentada durante toda a diligência, não sendo autorizada a acompanhar a busca realizada pelos policiais. Durante toda a diligência os policiais apontavam as suas armas para todos os presentes na casa. Afirmou que em nenhum momento o acusado saiu do imóvel. Disse que apesar de os policiais, no final da busca, terem afirmado que encontraram drogas no quarto do acusado, não viu eles saindo do imóvel com qualquer entorpecente. Contou que os policiais a levaram até a delegacia na condição de testemunha, permanecendo no local por cerca de três horas. Relatou que permaneceu sozinha em uma sala, sem a possibilidade de se comunicar com ninguém não tendo participado da ocorrência. Em certo momento, um policial pediu para que desbloqueasse o seu celular e, apesar de não concordar, forneceu a senha, pois não tinha nada a esconder. Afirmou que seu celular ficou apreendido desde o momento em que os policiais entraram no imóvel, até o final de toda ocorrência na Delegacia. Relatou que o acusado trabalha em uma pizzaria, das 18 até as 00h.

O réu RAPHAEL DO NASCIMENTO LEAL, interrogado, negou os fatos narrados na denúncia. Afirmou que no dia dos fatos, por volta das 07 horas da manhã, levou a sua filha para a escola, e retornou para a sua casa. Por volta do meio dia, foi buscá-la na escola, a deixando na casa de sua namorada. Por volta das 15 horas, Vaneza, a manicure da sua mãe chegou em sua casa. Pela parte da tarde, foi algumas vezes na cozinha para tomar café, ficando a maior parte do tempo sentado na sala assistindo televisão. Relatou que entre as 17 e 18 horas, ouviu fortes batidas em seu portão, avistando dois policiais entrando do imóvel. Perguntados sobre o motivo do ingresso forçado na residência, os policiais afirmaram que "a casa havia caído" e o algemaram. Em seguida, se dirigiram para o fundo da casa. Neste momento, levaram Vaneza, sua irmã e sua mãe para a sala. Os policiais apresentavam comportamento agressivo, gritando com sua irmã e mandando todos calarem a boca. Em certo momento, os policiais afirmaram ter encontrado drogas em seu quarto, porém não foi mostrado nenhum entorpecente enquanto ainda estavam no imóvel. Posteriormente foi conduzido até a delegacia, juntamente com o seu cunhado. Afirmou que só ficou sabendo da quantidade de droga e o motivo da sua prisão depois de dois meses que estava preso. Negou ter indicado para os policiais o local em que as drogas estavam. Contou que existe um ponto de tráfico de drogas próximo à sua casa. Negou ter comercializado qualquer droga como afirmado pelos policiais. Afirmou que a única ligação que tem com o tráfico é a compra de maconha, em razão da sua condição de usuário. Contou que o seu cunhado também é usuário de maconha. Disse que em nenhum momento ocorreu a perseguição narrada pelos policiais. Relatou que durante a busca em sua casa, os policiais não autorizaram que nenhum dos presentes acompanhasse a diligência, permanecendo todos na sala. Em nenhum momento os policiais mostraram as fotos que afirmaram ter tirado da sua conduta.

Este é o cerne do conteúdo probante angariado ao feito.

O presente processo iniciou com a prisão em flagrante do acusado Raphael do Nascimento Leal, sob o fundamento de prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão de ter sido localizada em sua residência 112,2 gramas de cocaína, e cerca de 205,4 gramas de maconha.

Disseram os policiais Fábio e Heictor que o local dos fatos é conhecido como ponto de tráfico de drogas, passando rotineiramente por lá. Dois dias antes dos fatos, através da realização de breve campana, observaram o acusado saindo de sua casa, indo até terceiros na ponte do canal 06, entregando algo a eles, e retornando ao imóvel, repetindo essa dinâmica diversas vezes, tendo afirmado que registraram a conduta do acusado através de fotos e vídeos.

No dia dos fatos, afirmaram que foram novamente até a residência do acusado em uma viatura descaracterizada, e perceberam a repetição da movimentação observada nos dias anteriores. Desta forma, levando em consideração que o requerimento de mandado de busca e apreensão demandaria a elaboração de um relatório completo, tomaram o risco de entrar na residência do acusado sem mandado de busca e apreensão, após breve perseguição.

Relataram que conseguiram alcançar o acusado no interior do imóvel, na sala de estar, local onde foi abordado. Nesta oportunidade o acusado confessou informalmente a prática do crime, indicando que as drogas estavam armazenados em um rack no seu quarto.

Os policiais também afirmaram que a busca foi realizada em todo o imóvel, tendo sido acompanhada pelo chefe de investigação bem como pela mãe do acusado. Por fim, relataram que o acusado trabalhava para um traficante denominado "MK".

Em sentido completamente diverso, o acusado, em seu interrogatório, negou os fatos narrados na denúncia. Afirmou que no dia dos fatos, apenas saiu de sua residência para levar e buscar sua filha na escola, permanecendo no imóvel durante toda a parte da tarde, negando a perseguição narrada pelos policiais.

Entre as 17 e 18 horas, os policiais forçaram a sua entrada pelo portão, algemaram o acusado e conduziram todos os presentes até a sala, enquanto realizavam a busca pelos outros cômodos do imóvel sem qualquer acompanhamento.

Os policiais apresentavam comportamento agressivo durante toda a diligência, gritando com a sua irmã e mandando todos calarem a boca. O acusado negou ter indicado para os policiais o local em que os entorpecentes estavam armazenados, relatando que em algum momento da busca, eles afirmaram que haviam encontrado drogas, porém os entorpecentes apenas apareceram na delegacia.

Os depoimentos das testemunhas de defesa Cristiano, Vaneza, Isley e Beatriz corroboram a versão apresentada pelo acusado, no sentido de que ele permaneceu no imóvel durante toda a parte da tarde, tendo os policiais forçado a sua entrada na residência, apresentando comportamento agressivo durante toda a busca, a qual não foi acompanhada por nenhum dos presentes e, apesar de os policiais terem afirmado que encontraram entorpecentes no quarto do acusado, eles só foram mostrados na delegacia.

Em que pese a declaração das testemunhas policiais de que a diligência, que culminou com a prisão do acusado, foi precedida de campanhas realizadas em dias anteriores, inclusive com o registro da conduta do acusado através de fotos e vídeos, nenhum desses elementos investigativos foram juntados aos autos.

De nada adianta o trabalho investigativo se ele não vier documentado para os autos do processo. O que se tem no presente caso é o auto de prisão flagrante e as declarações das partes sobre o ocorrido.

De igual modo, em razão das versões antagônicas apresentadas pelos policiais e pelas testemunhas de defesa e pelo acusado, também não há como ter certeza se de fato houve a perseguição do acusado antes da entrada dos policiais em sua residência.

De mais a mais, não há qualquer elemento probatório juntado aos autos capaz demonstrar que o acusado trabalhava para um traficante conhecido como "MK".

Em relação à alegação do Ministério Público sobre a diferença entre o horário que a diligência policial começou, e o horário relatado pela testemunha Cristiano, em relação ao início da atuação dos policiais, percebe-se que tal confusão é

plenamente justificada em razão do lapso temporal transcorrido entre os fatos e a audiência de instrução e julgamento. Cabendo ressaltar, que apesar da pequena imprecisão do seu depoimento, o horário relatado pela testemunha não destoa de forma significativa do horário em que os fatos ocorreram, não sendo suficiente para levantar dúvidas sobre a veracidade dos demais elementos contidos no seu depoimento.

Não se pode perder de vista, ainda, que a busca e apreensão realizada no dia da prisão em flagrante do acusado, foi realizada sem qualquer ordem judicial.

A busca e apreensão domiciliar é regida, constitucionalmente, pelo disposto no artigo 5º, XI, da CF/88: "A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial."

O primeiro ponto a se analisar, portanto, é a hipótese de ingresso com consentimento do morador e, para tanto esse consentimento deve ser válido.

Guilherme Madeira Dezem bem destaca: "O consentimento do morador deve ser analisado com cautela. Assim, por se tratar de exceção constitucional precisamos lembrar que a qualquer tempo poderá ser retirado o consentimento. (...) De nada adianta a Constituição Federal erigir um castelo em torno do domicílio, se este castelo pode ser aberto de qualquer forma, pois seus portões são de papelão" (Curso de Processo Penal, 8ªed. RT, p. 834).

Na mesma linha, o E. Min. Rogério Schietti Cruz bem destacou: "O direito à inviolabilidade de domicílio, dada a sua magnitude e seu relevo, é salvaguardado em diversos catálogos constitucionais de direitos e garantias fundamentais. Célebre, a propósito, a exortação de Conde Chatham, ao dizer que: 'O homem mais pobre pode em sua cabana desafiar todas as forças da Coroa. Pode ser frágil, seu telhado pode tremer, o vento pode soprar por ele, a tempestade pode entrar, a chuva pode entrar, mas o Rei da Inglaterra não pode entrar!'" (STJ, T6, HC 598051/SP, DJE 02.03.21).

Do depoimento das testemunhas Cristiano, Vaneza, Isley e Beatriz, é possível verificar que não houve o consentimento do réu para que houvesse a entrada dos policiais no imóvel, os quais forçaram a entrada na residência, o que fica ainda mais evidente quando esses depoimentos são analisados em conjunto com as fotos de fls. 81/86, as quais demonstram sinais de arrombamento na porta da casa do acusado.

Nesse raciocínio, comporta verificar que diante controvérsia em relação à autorização do morador (no caso o acusado) para ingresso dos policiais em seu domicílio, deve vigorar o princípio do in dubio pro reo, ou seja, deve ser considerado que o acusado não é obrigado a produzir prova contra si próprio (nemo tenetur se detegere).

E, segundo julgado do E. STJ (HC 598051/SP), o ônus da prova da legalidade da entrada no domicílio é do Estado.

No mesmo sentido as lições de Renato Brasileiro de Lima: "Para validar o ingresso de agentes estatais no interior da casa e subsequente busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, o consentimento do morador precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. Na visão dos Tribunais Superiores, a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. (...) A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrem em relação de causalidade (...)." (Manual de Processo Penal, Editora JusPodium, 10ªed. , p. 696).

Portanto, considerando a inexistência de qualquer comprovação da autorização do acusado para o ingresso dos policiais em sua residência e, diante da versão por ele apresentada, a qual foi corroborada pelas testemunhas Cristiano, Vaneza, Isley e Beatriz, a partir daqui, se analisa o flagrante, considerando que o ingresso dos policiais no domicílio do acusado ocorreu sem a sua permissão e, por conta disso, deve ser analisado a situação do flagrante de crime permanente, pois, no caso, o crime de tráfico de drogas se protraía no tempo, ou seja, a ofensa ao bem jurídico protegido remanesceu durante todo o período de tempo em que as drogas permaneceram

no imóvel do acusado.

Desta forma, passa-se a analisar a busca e apreensão, sem mandado judicial e sem autorização do acusado para ingresso na sua residência, mas sob a alegação de se estar diante da segunda hipótese de permissão constitucional para a violação do domicílio, ou seja: em caso de flagrante delito.

E, sob esse aspecto, tem-se que a medida também se mostrou ilegal.

No caso sob análise, segundo os policiais, após realizarem breves campanhas, visualizaram o acusado em atitude típica de traficância e, no dia da prisão, no momento que decidiram abordá-lo, o acusado fugiu e foi perseguido até a sua casa, local em que foi abordado.

Contudo, o acusado afirmou que permaneceu em casa durante todo o período da tarde, declaração que foi corroborada pelas testemunhas Vaneza, Isley e Beatriz. Desta forma, não há provas que de fato a entrada forçada dos policiais foi precedida de perseguição.

De mais a mais, cumpre salientar, que ainda que existissem provas que de fato os policiais perseguiram o acusado, a fuga por si só, não é suficiente para legitimar a entrada dos policiais no imóvel.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUGA DO AGENTE. FUNDADAS RAZÕES. NÃO OCORRÊNCIA. ILICITUDE DE PROVAS RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. AGRAVO DESPROVIDO (...) 2. Na hipótese, não se verifica a presença de justa causa necessária para legitimar o ingresso dos policiais na residência em questão, visto que, conforme se extrai do caderno processual, durante patrulhamento na localidade, os agentes avistaram o paciente, acompanhado dos corréus Anderson e Lucão, com comportamento supostamente suspeito, e, quando os acusados visualizaram a viatura, teriam corrido. Consoante relatado, o paciente teria fugido em direção a uma residência, razão pela qual os policiais decidiram adentrar no imóvel. 3. Esta Corte já se manifestou que a mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo paciente, embora pudesse autorizar abordagem policial, em via pública, para averiguação, não configura, por si só, justa causa a permitir o ingresso em seu domicílio, sem seu consentimento - que deve ser mínima e seguramente comprovado - e sem determinação judicial (HC n. 415.332/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21/8/2018). 4. Assim, a simples fuga do agente para o interior do imóvel, ao avistar os agentes de segurança, por si só, não configura justa causa suficiente para autorizar a mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio (...) (STJ - AgRg no HC: 728853 RS 2022/0070557-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022) Grifei.

Portanto, não se pode afirmar que havia indícios concretos da prática do crime de tráfico de drogas por parte do acusado.

Sobre a matéria o C. STF já pacificou: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas “a posteriori”, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. Essa a orientação do Plenário, que reconheceu a repercussão geral do tema e, por maioria, negou provimento a recurso extraordinário em que se discutia, à luz do art. 5º, XI, LV, LVI, da CF/1988, a legalidade das provas obtidas mediante invasão de domicílio por autoridades policiais sem o devido mandado de busca e apreensão” (STF, RE 603.616/RO, rel. Mim. Gilmar Mendes, DJe 10.05.2016).

Analisando a situação, Guilherme Madeira Dezem pondera: “O problema reside na análise dos motivos que levaram à entrada do domicílio sem mandado. Não se pode fazer aqui o raciocínio do resultado para a ação desenvolvida, valendo-se do resultado como legitimador da conduta. Esse raciocínio pernicioso põe ao chão a proteção constitucional do domicílio.” (Curso de Processo Penal, 8ªed. RT, p. 836). Por conseguinte, o fato de ter sido localizado algo ilícito e que configura crime permanente no domicílio não significa, necessariamente, que a conduta desenvolvida pelos agentes foi correta. Do mesmo modo que, não localizar nada, não significa que a conduta dos policiais foi ilegal.

Destaca o citado doutrinador: “O que precisará ser feito pelo Poder Judiciário é ignorar o resultado e analisar os motivos dados pelos agentes para a entrada no domicílio, somente assim teremos a análise concreta dos motivos que ensejaram a entrada no domicílio e poderá haver o concreto controle judicial” (Dezem, Guilherme Madeira. Curso de Processo Penal, 8ªed. RT, p.836).

Assim sendo, no caso concreto em análise, tem-se que a conduta dos policiais de ingresso forçado no domicílio do acusado foi ilegal, justamente porque não tinham motivos concretos mínimos para justificar o ingresso, sob o argumento de ocorrência de crime de tráfico de drogas no local.

Ficou evidente pela instrução processual, que o ingresso dos policiais no domicílio do acusado não foi precedido de mínima investigação para averiguar as informações apontadas na denúncia.

Consequentemente, o encontro de entorpecentes no domicílio do acusado foi fato fortuito e inesperado.

Considerando, portanto, o encontro fortuito de provas, a validade destas seguirá o mesmo destino da medida que lhe deu origem, ou seja, se válida a medida anterior, válida será essa prova fortuitamente localizada; todavia, se ilícita a medida anterior, inválida também será essa prova fortuitamente localizada.

Mesmo entendimento é esposado pelo STF no julgamento do HC 129.678/SP, rel. Min. Alexandre de Moraes (DJe 18.08.2017), e no STJ no julgamento do AgRg no REsp 1.752.564, Rel. Min. Ribeiro Dantas (5ªT, DJe 23.11.2020).

Assim sendo, no caso em análise, temos que inválida a localização dos entorpecentes no domicílio do acusado, uma vez que inválida a medida de busca e apreensão realizada pelos policiais.

Deste modo, pelas provas produzidas nos autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não é possível se concluir pela responsabilidade penal do acusado, ante o conjunto probatório extremamente frágil e inconsistente.

Nesse sentido, Nelson Hungria assinala que “a condenação criminal somente poderá surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência”. (in, Da Prova no Processo Penal, Editora Saraiva, 1983, p. 46).

É cediço que o magistrado deve pautar a sua atuação no livre convencimento, entretanto, deve existir nos autos provas que indiquem a certeza da autoria e materialidade do delito, caso contrário, deverá incidir o princípio do in dubio pro reo.

Ademais, o princípio do in dubio pro reo não é só uma garantia em favor do acusado, mas também um alento para o Estado-Juiz, que diante da falta de elementos convincentes para condenar, pode e deve absolver, sem que isso signifique uma declaração de inocência comprovada.

Desta forma, a melhor solução é a absolvição por falta de provas, já que o Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades e, sem a certeza total e plena da autoria e materialidade do delito imputado ao acusado, não pode ser proferida a condenação.

Portanto, é de rigor que seja aplicado o princípio do in dubio pro reo, e consequentemente, o réu seja absolvido.

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal, para ABSOLVER o acusado RAPHAEL DO NASCIMENTO LEAL, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em relação aos fatos descritos na denúncia.

Defiro que o réu aguarde o resultado de eventual recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Também após o trânsito em julgado, oficie-se à Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, autorizando a imediata destruição dos entorpecentes nos termos previstos em lei, remetendo-se auto competente.

P.I.C.

Santos, 07 de julho de 2022.

Leonardo de Mello Gonçalves
Juiz de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA